



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000378260

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000195-79.2016.8.26.0630, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante JOSE EDUARDO VARANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.

São Paulo, 22 de maio de 2018.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

16ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000195-79.2016.8.26.0630

Comarca: HORTOLÂNDIA

Apelante: JOSÉ EDUARDO VARANDA

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO nº 32444

LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Preliminar afastada. Tese defensiva apreciada pelo Juízo a quo. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas pelos depoimentos da vítima, da testemunha presencial e laudo pericial. Versão defensiva isolada nos autos. Não comprovação da inimputabilidade penal e da legítima defesa. Ônus que cabia à defesa. Condenação mantida. Penas reformuladas. Sursis. Imposição das condições previstas apenas no artigo 78, §2º do CP. Imposição da condição especial de prestar serviços à comunidade pelos primeiros três meses. Sursis mais gravoso do que a pena imposta. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 493 do STJ. Exclusão da condição especial. Imposição das condições previstas no art. 78, §2º do Código Penal. Cabimento do regime inicial aberto. Apelo parcialmente provido.

1. JOSÉ EDUARDO VARANDA foi condenado, pela r. sentença de fls. 215/219, à pena de 4 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 129, § 9º, do CP, suspensa pelo prazo de dois anos e quatro meses, mediante comparecimento mensal ao juízo e proibição de viajar ou de mudar para outra comarca, sem autorização do juiz devendo, no primeiro ano, prestar serviços à comunidade.

De acordo com a denúncia julgada procedente, no dia 23 de março de 2016, por volta das 21 horas, na Rua Gênova, nº 45, Jardim Residencial Firenze, comarca de Hortolândia, prevalecendo-se das relações domésticas e íntimas, com violência contra a mulher, ofendeu a integridade



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

física de sua esposa Tatiana Borlote Varanda, mediante empurrão e socos, provocando-lhe lesões nos braços e nas costas.

Inconformada a Defesa argui preliminar de nulidade por falta de fundamentação da sentença. No mérito, articula, em síntese, que a dependência química do acusado exclui sua culpabilidade penal. Também aduz que a conduta não foi antijurídica, porque praticada em legítima defesa, sem o dolo de lesionar a vítima. Subsidiariamente, requer a atenuação da reprimenda em razão da confissão espontânea, exclusão das condições impostas cumulativamente no *sursis* e fixação do regime inicial aberto, levando-se em conta que o acusado já permaneceu preso provisoriamente por três meses (fls. 257/269).

O recurso foi contrarrazoado (fls. 272/277), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Eduardo Rheingantz, pelo parcial provimento a fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal e fixar o regime inicial aberto (fls. 286/287).

É o relatório.

2. O feito não padece de nulidade.

Aduz a defesa ser a sentença nula, por ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, na medida em que o juízo *a quo* não teria apreciado as teses de exclusão da antijuridicidade da conduta e imputabilidade penal.

Não verifico a mácula apontada por reconhecer na decisão recorrida que o magistrado expôs tratar-se de agente culpável, não se justificando por qualquer forma as lesões que provocou em sua esposa.

No mérito, a condenação era medida de rigor.

Consta da inicial que as partes estão casadas há 14 anos e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

possuem 3 filhas, existindo histórico de violência doméstica praticada pelo acusado contra a vítima.

A vítima, o réu e uma das filhas do casal, narraram que, no dia dos fatos, estando o réu totalmente embriagado, passou a discutir com a vítima, no interior da residência, na presença das filhas do casal, dessas circunstâncias sobrevivendo as agressões físicas.

A ofendida e sua filha mais velha descreveram, tanto em juízo quanto na fase inquisitiva, que o réu descontrolou-se empurrou a vítima e passou a desferir socos nela, ao passo que o réu alega ter sido a vítima quem investiu contra ele, assim provocando sua autodefesa.

A narrativa do acusado a respeito da dinâmica dos fatos não foi confirmada por qualquer elemento de prova, não tendo ele demonstrado que houve injusta provocação anterior por parte da ofendida, requisitos estes para o reconhecimento da legítima defesa.

A testemunha e a vítima corroboraram que foi o acusado quem deu início às agressões, ainda que a ofendida tenha revelado ter mordido o dedo do réu para se defender.

Vale lembrar que a ocorrência das lesões e sua autoria encontram-se devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, de suas filhas, bem como pelo laudo pericial de fls. 207/208; cabendo à Defesa o ônus de comprovar a ocorrência da suposta causa excludente de ilicitude.

Da mesma forma, não pairam dúvidas sobre a culpabilidade penal do acusado, pois a embriaguez pré-ordenada não é causa para a inimputabilidade.

Mais uma vez, era ônus da defesa requer a instauração de incidente de sanidade mental/dependência toxicológica, o qual, também



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

não pleiteou a fim de angariar provas de sua tese.

Enfim, mais não é preciso para manter a condenação criminal.

As penas comportam reforma.

A pena-base foi fixada $\frac{1}{2}$ acima do mínimo, porque a vítima relatou já ter sofrido outras agressões do réu, o qual já foi condenado em Primeira Instância pelo mesmo crime. Também se valorou que o réu provocou lesões múltiplas na ofendida, bem como que praticou o crime na presença de crianças, que são suas filhas.

Dos aspectos elencados, reconheço que os dois primeiros não justificam a imposição de pena mais severa ao acusado. Primeiro porque falta prova cabal de que o réu tenha agredido a vítima em oportunidade anteriores, pois inexistente condenação criminal definitiva neste sentido. Em segundo lugar, as lesões sofridas pela vítima integram a própria conduta delitiva, não podendo ser valorada em duplicidade contra o acusado.

Contudo, reconheço que a violência praticada contra a esposa, dentro de casa, na presença das filhas menores é circunstância prejudicial ao agente pois impacta negativamente na construção do senso de segurança e autoconfiança das menores.

Assim, fixo a pena-base $\frac{1}{6}$ acima do mínimo, em 3 meses e 15 dias de reclusão.

Na segunda fase, em que pesem as teses defensivas, de rigor considerar que o acusado assumiu ter agredido a vítima, motivo pelo qual, a meu ver, deve incidir a atenuante da confissão, reduzindo a reprimenda ao mínimo legal.

Inexistentes causas especiais de aumento ou diminuição das penas, torno a reprimenda definitiva em 3 (três) meses de detenção.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

À vista do quantum imposto, da primariedade e confissão, entendo que o réu faz jus ao cumprimento da pena em regime inicial aberto.

Analizando a pena privativa de liberdade imposta, lembramos que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que o cumprimento da pena em regime aberto não pode ser cumulado com a imposição de prestação de serviços à comunidade, por caracterizar *bis in idem*:

“Súmula nº 493: É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto”.

Vale dizer, portanto, que o cumprimento da pena privativa de liberdade não poderia importar a fixação de prestação de serviços à comunidade pelo acusado.

Por outro lado, a suspensão condicional da pena, nas palavras de Cuello Calon, citado por Cezar Roberto Bitencourt, “*não só constitui um substitutivo penal das penas privativas de liberdade, como também um meio de eficácia educadora, pois, durante o período de prova, o condenado se habitua a uma vida ordenada e conforme a lei*” (Tratado de Direito Penal, v.1, Parte Geral, Editora Saraiva, 2012, p. 783).

Com efeito, a suspensão deve ser mais benéfica do que o cumprimento da pena privativa de liberdade, de modo que, se a pena de detenção não pode ser cumprida com a imposição de qualquer das penas substitutivas previstas no art. 44 do Código Penal, a suspensão também não poderá.

Assim, afasto a condição imposta pelo magistrado sentenciante (de prestação de serviços à comunidade pelos 3 primeiros meses de suspensão), impondo ao acusado as condições previstas no art. 78, §2º, 'b' e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

'c' do Código Penal, quais sejam: a proibição de ausentar-se da comarca onde reside e o comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

3. Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do acusado a 3 (três) meses de detenção, fixar o regime inicial aberto e para substituir a condição especial de prestação de serviços à comunidade pelas condições previstas no art. 78, §2º, 'b' e 'c' do Código Penal, no primeiro ano da suspensão.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator